



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PENAL MILITAR
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
AULA 3

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. CRIME CONSUMADO E CRIME TENTADO
2. ELEMENTOS NÃO CONSTITUTIVOS DO CRIME
3. ANTIJURIDICIDADE
4. CULPABILIDADE

- **CRIME CONSUMADO E CRIME TENTADO**

➤ Previsão no CPM (próximo ao art. 14 do CP).

➤ **Mesma concepção do *iter criminis*:**

- cogitação (*cogitatio*),
- atos preparatórios (*conatus remotus*),
- a execução (*conatus proximus*) e
- a consumação (*meta optata*).

➤ **Desistência voluntária e arrependimento eficaz:** art. 31 do CPM igual ao art. 15 do CP.

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ – QUADRO COMPARATIVO	
CPM	CP
“Desistência voluntária e arrependimento eficaz Art. 31. O agente que, voluntariamente, <u>desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza</u>, só responde pelos atos já praticados. Crime impossível Art. 32. Quando, por <u>ineficácia absoluta do meio empregado</u> ou por <u>absoluta impropriedade do objeto</u>, é impossível consumir-se o crime, nenhuma pena é aplicável”. “Art. 72. São circunstâncias que sempre <u>atenuam a pena</u>: III - ter o agente: b) procurado, por sua <u>espontânea vontade</u> e com <u>eficiência</u>, logo após o crime, <u>evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências</u>, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano” (igual ao art. 65, III, “b”, do CP).	“Desistência voluntária e arrependimento eficaz Art. 15 - O agente que, voluntariamente, <u>desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza</u>, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Crime impossível Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por <u>ineficácia absoluta do meio</u> ou por <u>absoluta impropriedade do objeto</u>, é impossível consumir-se o crime”.

- Diferem da tentativa, embora chamada de tentativa inacabada: aqui o agente não consuma por sua vontade; na tentativa, o agente não consuma por motivos alheios à sua vontade. “Na tentativa, portanto, o agente quer, mas não pode, ao passo que, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele pode, mas não quer (Frank)” (Apud ESTEFAM, 2021, p. 131).

- **Arrependimento posterior:** art. 72, III, b, do CPM (atenuante), diferentemente do CP que prevê como causa genérica de diminuição de pena, no art. 16, com redução de 1/3 a 2/3 (além de atenuante também no art. 65, III, b).
- **Crime impossível** (tentativa inidônea): previsão no art. 32 do CPM com redação diversa do art. 17 do CP, mas com substância idêntica (“nenhuma pena é aplicável” e “Não se pune a tentativa”).

- São figuras, ademais, distintas:

- Na desistência o agente ainda pode prosseguir na execução, pois não esgotou o *iter criminis* (ex.: a arma possui mais projéteis, mas ele desiste de dispará-los).

- No arrependimento o agente já percorreu os atos executórios, mas antes de consumir efetivamente pratica ato para evitar o resultado da consumação (ex.: o sujeito descarregou sua arma e, diante da vítima ferida, arrepende-se e a socorre ao hospital).
- Requisitos: voluntariedade e eficiência.
- Natureza jurídica: majoritariamente, exclusão da tipicidade.
- Consequência de seu reconhecimento: “O agente só responde pelos atos já praticados (se forem típicos). Ocorre a chamada ‘ponte de ouro’ (expressão de Reinhard), desaparecendo o crime cuja execução se iniciara. Em outras palavras, significa dizer que o crime tentado, que já existia, não mais subsistirá. Por exemplo, se o sujeito efetua dois disparos contra a vítima, erra o alvo e, apesar de ter ainda cinco projéteis de arma de fogo, desiste de matá-la, só responde pelo disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003); há desistência voluntária e eficaz no tocante à tentativa de homicídio” (ESTEFAM, 2021, p. 132).

ARREPENDIMENTO POSTERIOR – QUADRO COMPARATIVO	
CPM	CP
?	Arrependimento posterior Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

- Possível analogia *in bonam partem*? Sim
- Não se esqueçam que há outros dispositivos, como a circunstância atenuante do art. 72, III, b, do CPM (atenuante), próxima do art. 65, III, b, do CP, o furto atenuado do § 2º do art. 240 do CPM, a questão do peculato culposo do § 4º do art. 303 do CPM etc.

ARREPENDIMENTO POSERIOR E A REFORMA DE 2023	
Lei n. 14.688/2023	VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Arrependimento posterior Art. 31-A. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.	“Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois o texto proposto, ao admitir a figura do arrependimento posterior nos crimes militares de modo indiscriminado, resultaria em estímulo negativo à manutenção da ordem e da dignidade das instituições militares, revelando-se incompatível com os princípios da hierarquia e da disciplina”.

CRIME IMPOSSÍVEL – QUADRO COMPARATIVO

CPM	CP
Crime impossível Art. 32. Quando, por <u>ineficácia absoluta do meio empregado</u> ou por <u>absoluta impropriedade do objeto</u> , é impossível consumir-se o crime, nenhuma pena é aplicável.	Crime impossível Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por <u>ineficácia absoluta do meio</u> ou por <u>absoluta impropriedade do objeto</u> , é impossível consumir-se o crime.

- Também chamado de tentativa inidônea ou inadequada ou, ainda, quase crime.
- A conduta não atinge o objetivo por:
 - Ineficácia absoluta do meio: tentar matar alguém com arma de brinquedo.
 - Impropriedade absoluta do objeto: atirar contra um cadáver, pensando que aquela pessoa ainda está viva.

CRIME IMPOSSÍVEL:

- É preciso que a ineficácia do meio ou impropriedade do objeto sejam absolutas, pois se relativas haverá crime tentado (ex.: acionar uma arma de fogo sem que haja a deflagração das munições ou tentar furtar alguém, que não possua valores no bolso), devendo-se compreender relativas aquelas meramente ocasionais ou circunstanciais e absolutas as constantes, permanentes (ESTEFAM, 2021, p. 133). **Teoria objetiva temperada.**
- Natureza jurídica: exclusão da tipicidade.

● ELEMENTOS NÃO CONSTITUTIVOS DO CRIME

➤ **Art. 47 do CPM:**

- “**Art. 47.** Deixam de ser elementos constitutivos do crime:

I - a qualidade de superior ou a de inferior hierárquico, quando não conhecida do agente;

II - a qualidade de superior ou a de inferior hierárquico, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão”.

➤ **Natureza jurídica:** exclui o dolo (tipicidade no CP ou culpabilidade no CPM).

- Não está tratando da tipicidade, mas sim de elemento do dolo.

➤ **Exemplos**

- Inciso I – agressão a pessoa e depois descobre que esta era militar e seu superior.
 - Não responde pelo crime de violência a superior.
 - Pelo que diz a norma, porque deixa de ser elementar do crime.
 - Na concepção do prof., porque não há dolo de agressão a superior.

- ex. discussão de trânsito; A desfere um soco em B; ao chegar uma guarnição para identificar e registrar a briga, descobre-se que A é cabo do exército e B é coronel do exército; note que não havia o conhecimento das patentes – **portanto não** pode ser crime de violência contra superior
- Inciso II - Ação praticada em repulsa a agressão (que pode ser moral).
 - Não é elemento constitutivo do crime.
 - **Veja que se fala em agressão:** física ou moral (não se fala em violência, fator que reduziria para agressão física)
 - Entende-se que não caracteriza legítima defesa, visto que nesta a repulsa ou agressão é em face de outra agressão atual ou iminente (em andamento ou na iminência de ocorrer); no caso do art. 47, a agressão já aconteceu
 - Ex. pelotão em posição de sentido; 1 militar está em posição de descansar; o tenente fala “cole os cascos, sua mula”; o cadete responde “quem tem casco é a vaca da sua mãe”; há o crime do art. 160, mas veja que foi proferida frase em repulsa a uma agressão anterior do tenente; aplicando o art. 47, II não há crime

Bloco 2

● ANTI JURIDICIDADE

- Antijuridicidade ganhou uma conotação material, possibilitando que seja antijurídico não somente aquilo que é contrário a norma geral, mas aquilo que substancialmente contrarie o senso atual de realidade do que é contrário ao direito.
- Previsão no CPM: arts. 42 a 46.
- **Há diferenças nas excludentes em relação ao CP:**

QUADRO COMPARATIVO DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE

CPM	CP
Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade; II - em legítima defesa; III - em estrito cumprimento do dever legal; IV - em exercício regular de direito. <u>Parágrafo único. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque.</u>	Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade; II - em legítima defesa; III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo <u>excesso doloso ou culposo</u> .

- Excludentes de ilicitude.
- Aqui começa a concepção subjetiva da ilicitude.

- Não basta, por exemplo, indivíduo estar formalmente em legítima defesa, é preciso que o agente tenha consciência da legítima defesa.

- Atenção: Excludente específica no parágrafo único que não está no CP.

- Excludente específica – uso da força para compelir o subordinado

- “Parágrafo único. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque.”

- Alguns, como o prof., entendem que isso nada mais é que estado de necessidade específico.

- Outros entendem que é exercício regular do direito do comandante e

- Outros, ainda, entendem que é estrito cumprimento do dever legal do comandante.

- **veja que não é qualquer pessoa**: comandante de navio, aeronave ou praça de guerra (atenção, ainda, para o estado específico de calamidade)

- Critério da proporcionalidade da excludentes (ex. seria proporcional tirar a vida de um subordinado para evitar o desânimo ou deserção?)

- o Professor entende que sim: em casos extremos é possível esse tipo de situação

NOVO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 NA REFORMA DE 2023	
Lei n. 14.688/2023	VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Art. 42 [...]. Parágrafo único. Não há igualmente crime quando o militar na função de comando, na iminência de perigo ou de grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas ou para evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque.” (NR)	“Em que pese a boa intenção do legislador, a proposição legislativa é contrária ao interesse público. A ampliação do instituto da excludente de ilicitude para uso da violência contra subalternos na iminência de perigo ou grave calamidade o tornaria aplicável potencialmente a todo militar em função de comando, o que causaria insegurança jurídica em razão da diversidade de interpretações possíveis em relação às hipóteses fáticas para as quais seria autorizado o uso da violência”.

Obs. consentimento do ofendido como excludente supra legal

- Ex. PM de elite quer tatuar o símbolo de sua unidade no braço; outro PM sabe fazer e acaba por tatuar esse colega dentro do próprio alojamento; a rigor, seria lesão corporal; contudo, houve o consentimento do ofendido
- Requisitos: bem deve ser disponível; proporcionalidade; antecedência do consentimento à conduta; confirmação subjetiva (deve saber do consentimento)

- **obs. as outras excludentes que existem no CPM são o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal**
 - Não possuem definição por artigos no CPM e no CP
 - A doutrina que dá o formato para essas excludentes
 - Como já falado, em algumas situações o consentimento do ofendido pode ser trazido como excludente supralegal no CPM
 - Exercício regular de um direito: confirmação subjetiva; proporcionalidade; também são requisitos
 - Nem tudo que contraria a norma pode ser tido como ilícito se a pessoa está exercendo seu direito
 - ex. PM envolvido com associação criminosa; é casado e confessa para a esposa essa atividade para a esposa, que também é PM; a esposa pode deixar de agir contra o marido, sem praticar prevaricação, já que o art. 296, p.u do CPPM traz o direito de não produzir prova incriminatória contra cônjuge
 - Estrito cumprimento do dever legal
 - a lei manda que exista uma ação
 - ex. PM prendendo em flagrante (as autoridades devem prender)
 - Mesma ideia de requisitos já citados (autoridade competente, proporcionalidade, etc.)

QUADRO COMPARATIVO DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE

CPM	CP
“Art. 43. Considera-se em <u>estado de necessidade</u> quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo <u>certo</u> e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, <u>desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado</u>, e o agente não era legalmente obrigado a <u>arrostar o perigo</u>” (Teoria Diferenciadora do Estado de Necessidade – Estado de Necessidade Justificante).	“Art. 24 - Considera-se em <u>estado de necessidade</u> quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. § 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de <u>enfrentar o perigo</u>. § 2º - Embora seja razoável exigir-se o <u>sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços</u>”.

- CP adotou a teoria unitária do estado de necessidade em que apenas justifica conduta
 - Afasta apenas a ilicitude
- No CPM há uma teoria diferenciadora
 - Dois estados de necessidade (atuando em dois elementos genéricos do crime):
 - O que justifica a conduta (Estado de necessidade justificante – art. 43) e o

- Exculpante que afasta a culpabilidade, possibilitando não apenas a redução de pena, mas até a isenção de pena.

- Observe que o “alheio” é referente a qualquer pessoa
- Atente-se para a natureza inferior do mal causado em relação ao mal evitado
- Não pode provocar o risco ao bem jurídico: para o professor, fala-se em provocação dolosa
- Perigo certo, inequívoco e atual – não basta ser iminente
- Ex. militar vai socorrer pessoa em risco de morte dentro do quartel; quebra viatura para fazer ligação direto e levar para o hospital
- Dever de arrostar (enfrentar) o perigo – exclui-se o estado de necessidade.
 - Bombeiro militar, por exemplo, o Direito não pode exigir sacrifício da vida. Há uma contemporização dessa previsão.
- Note que há sopesamento de bens no caso de o art. 43 do CPM
 - Há a exclusão de ilicitude quando o bem protegido é maior do que o bem sacrificado
 - Não pode nem ser igual
 - Estado de necessidade justificante
 - Já no CP não há essa ponderação entre bem sacrificado e bem protegido

QUADRO COMPARATIVO DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE

CPM	CP
“Art. 44. Entende-se em <u>legítima defesa</u> quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.	“Art. 25 - Entende-se em <u>legítima defesa</u> quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes”.

- ATENÇÃO para a alteração no art. 25 do CP: acréscimo do parágrafo único
 - “Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”
 - O professor defende que se trata de direito penal simbólico, já que, de toda forma, teria que passar pelo caput, não tendo qualquer utilidade a não ser apaziguar o público em foco (segurança pública)
- Mesma situação de legítima defesa do CP
- Conduta deve ser humana (se for animal, será estado de necessidade)

- Injusta agressão atual ou iminente.
- Ex. dois naufragos militares da marinha à deriva e se agarram a um baú; se ambos ficarem agarrados ele afundará e ambos morrerão; o naufrago A empurra B para o fundo do mar; B reage e atira no A;
- O ex. no CP: ambos em estado de necessidade
- O ex. no CPM: quando A tenta matar B, são bens iguais, sendo a ação de A injusta; quando B atira em A, está repelindo uma injusta agressão, agindo em legítima defesa
- obs. Em SP, há o entendimento de que o crime doloso contra a vida de civil, que será julgado pelo tribunal do júri, será um fato em que não haja a patente excludente de ilicitude (se houver a excludente, poderá, por promoção do MP, ser arquivado na própria justiça militar; ou então o juiz arquiva quando o MP suscita a incompetência da justiça militar, sendo entendido como promoção de arquivamento indireto

QUADRO COMPARATIVO DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE

CPM	CP
“Excesso culposo Art. 45. O agente que, em <u>qualquer dos casos de exclusão de crime</u>, <u>excede culposamente</u> os limites da necessidade, responde pelo fato, se este é punível, a título de culpa. Excesso escusável Parágrafo único. <u>Não é punível o excesso</u> quando resulta de <u>escusável surpresa</u> ou <u>perturbação de ânimo</u>, em face da situação. Excesso doloso Art. 46. O juiz <u>pode atenuar</u> a pena ainda quando punível o fato por <u>excesso doloso</u>” (redução de 1/5 a 1/3, pelo art. 73 do CPM).	“Art. 23 – [...]. Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo <u>excesso doloso ou culposo</u>”.

- Excesso culposo
 - Princípio da excepcionalidade do crime culposo
 - Sempre é necessário a previsão expressa da modalidade culposa
- Excesso escusável:
 - Caso de vários tiros quando se tem ânimo exaltado por algum motivo especial.
 - É preciso que o julgador veja isso como escusável.
 - Não há no CP
- Excesso doloso:
 - Quando o Código não fala pena mínima ou máxima, aplica-se o art. 58 do CPM
 - Ex. Caso do furto – pena reclusão até 6 anos. Pena mínima de 1 ano.
 - “**Art. 58.** O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.”

○ Quantum da agravação ou atenuação

- “**Art. 73.** Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime.”

➤ **QUESTÃO:**

○ **Quanto à antijuricidade, assinale a alternativa incorreta (Questão 5 - 10º Concurso MPM - 2010):**

A O Código Penal Militar, adotando a Teoria Diferenciadora, admite o estado de necessidade tanto como justificante quanto como exculpante.

B Não é possível legítima defesa contra quem pratica uma conduta acobertada por uma exculpante.

C No estado de necessidade justificante, o agente não é legalmente obrigado a arrostar o perigo.

D Não há que se falar em legítima defesa na conduta do militar que, em momento posterior à injusta provocação, agride um outro militar, em fuga, com golpe de facão, pois age com ânimo de revide e não de defesa.

Resposta: B.

(Legítima defesa deve ter repulsa por meios moderados, a uma agressão atual ou iminente e injusta; se a agressão for justa não há enquadramento em legítima defesa; exculpante exclui a culpabilidade e não a antijuricidade; a agressão é injusta, mas é exculpada; é possível legítima defesa acobertada por uma exculpante)

(ex. em um naufrágio, há duas pessoas [A e B] nadando para a tábua da salvação; essa tábua somente dará sustentação para uma delas; A empurra B para longe da tábua; A agride B, em ato executório de homicídio, mas em uma situação de estado de necessidade exculpante; veja que são bens jurídicos iguais [A protege sua vida e agride a vida de B]; no CPM é estado de necessidade exculpante ; portanto, A está praticando fato típico [homicídio], ilícito [já que não está acobertado pelo estado de necessidade justificante, porém não culpável [há o estado de necessidade exculpante]])

(se no exemplo acima, B reagir à agressão de A com um sinalizador, para ficar com a tábua; quando B repele a agressão de A [atual e injusta –não acobertada pelo estado de necessidade justificante-], estará em legítima defesa)

(se fosse no CP, não seria essa conformação; quando B repele a agressão de A, como A está em prática de agressão atual e justa, B não pode estar em legítima defesa; há o estado de necessidade diante de outro estado de necessidade)

(para a alternativa B estar correta, na questão acima, deveria dizer que não é possível legítima defesa contra quem pratica conduta acobertada por uma justificante; já que a agressão deve ser injusta)

○ **Acerca das causas excludentes do crime, assinale a alternativa incorreta (Questão 15 - 11º Concurso MPM - 2013).**

A. No Código Penal Militar existe uma causa de justificação especial que é a discriminante do comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, concedendo autoridade ao comandante para compelir seus subordinados a realizarem manobras e serviços urgentes, com a finalidade de salvaguardar quer vidas humanas, quer a própria unidade.

B. O estrito cumprimento do dever legal é causa de exclusão de ilicitude, prevista no Código Penal Militar de 1969, que não o conceitua, assim como não é conceituado no Código Penal. Ambos, porém, definem o estado de necessidade e a legítima defesa.

C. No direito militar pátrio, em matéria de legítima defesa, em que pese ser permitida a repulsa à “agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem”, serão sempre considerados elementos constitutivos do crime: a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa à agressão.

D. A diferença entre o estado de necessidade como excludente de culpabilidade e o estado de necessidade como excludente do crime, quanto aos requisitos que os constituem, é que, neste, o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo e, naquele, não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.

Resposta: C.

Bloco 3

- **CULPABILIDADE**

- **Teoria adotada no CPM:** teoria psicológico-normativa (Neokantismo).

- Culpabilidade com elementos subjetivos/psicológicos –dolo e culpa- (art. 33 do CPM) e normativos (arts. 39 e 48 do CPM) –estado de necessidade exculpante; imputabilidade; exigibilidade de conduta diversa-.

- **“Art. 33.** Diz-se o crime:

- I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

- II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.

Excepcionalidade do crime culposo

Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.”

- **“Art. 39.** Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.”

- **“Art. 48.** Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.”

➤ **Elementos da culpabilidade no CPM:**

- I) Imputabilidade: arts. 48 a 52 do CPM.
 - Adoção do critério bio-psicológico como utilizado no CP.
 - Não é capaz de entender a reprovação, portanto não é culpável
 - Critério cronológico (no momento da infração)
 - O parágrafo único prevê a existência dos semi-imputáveis – redução da pena.
 - Não suprime o entendimento, mas há diminuição
- II) Exigibilidade de conduta diversa (arts. 38 e 39 do CPM).
- III) Dolo (com a atual consciência da ilicitude – dolo normativo) e culpa (art. 33 do CPM).
 - A culpa no CPM é a descrição da culpa consciente e inconsciente, não descrevendo a imprudência, negligência e imperícia como no CP

➤ **IMPUTABILIDADE (CULPABILIDADE)**

QUADRO COMPARATIVO

CPM	CP
“Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de <u>doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado</u>”. (critério biopsicológico). “Redução facultativa da pena Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem prejuízo do disposto no art. 113” (redução de 1/5 a 1/3, pelo art. 73 do CPM). Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), sem prejuízo do disposto no art. 113 deste Código (redação da Lei n. 14.688/2023). - Obs.: art. 113 do CPM permite a substituição de pena por internação, tal qual o art. 98 do CP.	“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por <u>doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado</u>, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente <u>incapaz de entender</u> o caráter ilícito do fato ou de <u>determinar-se</u> de acordo com esse entendimento” (critério biopsicológico). “Redução de pena Parágrafo único - A pena pode ser <u>reduzida de um a dois terços</u>, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado <u>não era inteiramente capaz de entender</u> o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

- Não adianta a presença da conduta reprovável, se não houver a valoração da conduta alheia quanto a imputabilidade
- Mentalmente hígida e capacidade de entender sua conduta
- Critério cronológico (momento da ação ou omissão)
- Critério biológico (doença mental – pode ser temporária) e critério psicológico (pessoa não consegue entender o caráter ilícito da conduta. **Daí entra o critério biopsicológico.**

- Mesmo critério adotado pelo CP
- O juiz absolve ou condena em sentença
- Ao absolver e aplicar medida de segurança, há a absolvição imprópria
- Há a possibilidade de semi-imputabilidade (diminuição da capacidade – não da supressão), que implica em redução da pena.
- Obs. as vezes o inimputável age em legítima defesa; note, portanto, que a inimputabilidade não deve obstar a instrução criminal

QUADRO COMPARATIVO – EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA

CPM	CP
“Art. 49. <u>Não é igualmente imputável</u> o agente que, por <u>embriaguez completa</u> proveniente de <u>caso fortuito</u> ou <u>força maior</u>, era, <u>ao tempo da ação ou da omissão</u>, inteiramente <u>incapaz de entender</u> o caráter criminoso do fato ou de <u>determinar-se</u> de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. A pena <u>pode ser reduzida de um a dois terços</u>, se o agente por <u>embriaguez</u> proveniente de <u>caso fortuito</u> ou <u>força maior</u>, <u>não possuía</u>, <u>ao tempo da ação ou da omissão</u>, a <u>plena capacidade</u> de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.	“Art. 28 – [...]. § 1º - É <u>isento de pena</u> o agente que, por <u>embriaguez completa</u>, proveniente de <u>caso fortuito</u> ou <u>força maior</u>, era, <u>ao tempo da ação ou da omissão</u>, inteiramente <u>incapaz de entender</u> o caráter ilícito do fato ou de <u>determinar-se</u> de acordo com esse entendimento. § 2º - A pena <u>pode ser reduzida de um a dois terços</u>, se o agente, por <u>embriaguez</u>, proveniente de <u>caso fortuito</u> ou <u>força maior</u>, <u>não possuía</u>, <u>ao tempo da ação ou da omissão</u>, a <u>plena capacidade</u> de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

- Fala-se em embriaguez completa e que não seja voluntária (teoria da actio libera in causa – a embriaguez voluntária prejudica o acusado, conforme se verá abaixo)
- Por álcool ou qualquer substância que produza o mesmo efeito
- Se a Embriaguez involuntária trazer incapacidade total de entender – inimputabilidade – será isento de pena.
- Se Embriaguez involuntária incompleta – semi-imputabilidade – haverá redução de pena

QUADRO COMPARATIVO – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA (*ACTIO LIBERA IN CAUSA*)

CPM	CP
“Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime: I – [...]; II - ter o agente cometido o crime: [...]; c) depois de embriagar-se, salvo se a embriaguez decorre de caso fortuito, engano ou força maior; [...]. Parágrafo único. As circunstâncias das letras <i>c</i> , salvo no caso de embriaguez preordenada, <i>l</i> , <i>m</i> e <i>o</i> , só agravam o crime quando praticado por militar”. - Obs.: a voluntária, mesmo sem ser preordenada agrava a pena para o militar; para o civil, apenas quando preordenada.	“Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal: I – [...]; II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”. “Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I – [...]; II - ter o agente cometido o crime: [...]; l) em estado de embriaguez preordenada”.

- Lembre-se que a embriaguez voluntária prejudica o acusado
- AGRAVANTE PELA EMBRIAGUEZ (segunda fase do critério de trifásico da pena):
 - **Embriaguez voluntária** – agrava a pena do militar em qualquer situação (mesmo que não seja preordenada)
 - observe que no CP somente agrava se for preordenada: não importa quem seja o agente.
 - **Embriaguez pré-ordenada** – agente se embriaga para depois cometer crime.
 - Está destacada no CPM para agravar a pena para o civil que cometa crime militar
 - Portanto, para o militar, a embriaguez voluntária agrava sendo ou não pré-ordenada

QUADRO COMPARATIVO – “CRIMES DE EMBRIAGUEZ”

CPM	LPE
EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO “Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo: Pena - detenção, de seis meses a dois anos”.	“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. § 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

- Embriaguez também é tratada como crime específico no CPM – embriaguez do militar que está em serviço

QUADRO COMPARATIVO – MAIORIDADE PENAL

CPM	CP/CF/ECA
“Art. 50. O menor de dezoito anos é inimputável, salvo se, já tendo completado dezesseis anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com este entendimento. Neste caso, a pena aplicável é diminuída de um terço até a metade. “Art. 51. Equiparam-se aos maiores de dezoito anos, ainda que não tenham atingido essa idade: a) os militares; b) os convocados, os que se apresentam à incorporação e os que, dispensados temporariamente desta, deixam de se apresentar, decorrido o prazo de licenciamento; c) os alunos de colégios ou outros estabelecimentos de ensino, sob direção e disciplina militares, que já tenham completado dezessete anos. Art. 52. Os menores de dezesseis anos, bem como os menores de dezoito e maiores de dezesseis inimputáveis, ficam sujeitos às medidas educativas, curativas ou disciplinares determinadas em legislação especial”.	CP: “Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. CF: “Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”. ECA: “Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato”.

- Menores de 18 anos são penalmente inimputáveis.
- Veja que o artigo 50 está em dissonância com a CF/88: trata o maior de 16 e o menor de 18 como imputável no critério de discernimento;
 - bem como o art. 51 Art. “51 do CPM – militar menor de 18 anos que pratica crime se equipara a maiores de 18 anos. “
 - equipara ao maior de 18 o militar em qualquer idade, nos casos especificados nas alíneas
- CF no art. 228 determina de maneira clara que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, portanto é o que vige (**teoria da recepção**: art. 50, segunda parte e o art. 51 não foram recepcionados)

- Militar menor de 18 anos que pratique fato tido como crime militar: pelo art. 103 do ECA comete ato infracional.
 - Se é adolescente não será crime militar (será ato infracional)

QUADRO COMPARATIVO – MAIORIDADE PENAL

CPM	CP/CF/ECA
“O menor de 18 (dezoito) anos é penalmente inimputável, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial” (<i>redação da Lei n. 14.688/2023</i>).	CP: “Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. CF: “Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”. ECA: “Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato”.

Bloco 4

➤ EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA (CULPABILIDADE)

QUADRO COMPARATIVO – COAÇÃO

CPM	CP
“Art. 38. Não é culpado quem comete o crime: a) sob <u>coação irresistível</u> ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade; b) [...]. § 1º - <u>Responde pelo crime o autor da coação</u> ou da ordem. § 2º - [...]. “Art. 40. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível senão quando física ou material”. Obs.: 1) Pelo art. 40, entende-se que o art. 38 se refere a qualquer coação. 2) Possível resquício causalista, em que nem a coação física eliminaria a conduta, avaliando-se a questão na culpabilidade.	“Art. 22 - Se o fato é cometido sob <u>coação irresistível</u> ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, <u>só é punível o autor da coação</u> ou da ordem”. Obs.: aqui fala-se na coação moral, já que a física exclui a própria conduta (Finalismo).

- Coação.
 - Alguns doutrinadores entendem que aqui há unificação da coação física e moral.
 - A rigor, a coação moral torna o ato involuntário e a coação física também afasta a responsabilização penal.
 - Coação deve ser irresistível

- O coator pode responder pelo delito (veja que retira a responsabilidade do coagido, mas permite a responsabilização do coator)
 - A coação, como excludente da culpabilidade, pode ser tanto física quanto moral
- Coação física ou material
- “**Art. 40.** Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível senão quando física ou material.”
 - Note que há uma especificidade da coação nesse dispositivo
 - Por essa razão, ao delimitar no art. 40, entende-se que o art. 38 abarca a coação física e a moral
 - Nos casos de crimes contra o dever militar (Art. 183 a 204) somente se aplica a coação física para excluir a culpabilidade (ex. bandido mantém família de militar responsável pelo arsenal refém; manda esse militar buscar armas enquanto a família está refém; veja que é coação moral; nesse caso não há excludente de ilicitude quanto ao crime contra o dever militar)

QUADRO COMPARATIVO – OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA

CPM	CP
“Art. 38. Não é culpado quem comete o crime: a) [...]; b) em <u>estrita obediência</u> a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços. § 1º - Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. § 2º - Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato <u>manifestamente criminoso</u>, ou há excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior hierárquico” (redação da Lei n. 14.688/2023). Obs.: 1) Adoção do princípio das baionetas inteligentes e não da baionetas ou obediência cega. 2) E a ordem manifestamente ilegal e não criminosa? Ex.: improbidade administrativa. 3) Atenção ao crime de recusa de obediência (art. 163, CPM).	“Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em <u>estrita obediência a ordem</u>, não <u>manifestamente ilegal</u>, de superior hierárquico, <u>só é punível o autor da coação ou da ordem</u>”.

- Obediência hierárquica – regra:
- O autor da ordem responde
 - Quem cumpre a ordem está isento
- §2º: Ordem manifestamente criminosa ou excesso no cumprimento da ordem:
- Agente responde pelo crime juntamente com o superior que deu a ordem.
 - Brasil adota o princípio das baionetas inteligentes (obediência inteligente) – não obrigatoriedade ou cumprimento de ordem quando for manifestamente criminosa. – CPM
 - Em contraposição a essa teoria, há a teoria das baionetas cegas (obediência cega): ordem é ordem e não se deve questionar; se cumpre

- Ao não cumprir essa ordem, não será responsabilizado por recusa de obediência (art. 163)
- CP – ordem manifestamente ilegal não precisa ser cumprida. (veja que difere do CPM que fala em ordem manifestamente criminosa)
 - Ilícito como gênero: o crime é espécie
 - Parte da doutrina utiliza essa diferenciação
 - O professor Cícero equipara, dizendo que, mesmo no CPM, a ordem que não deve ser cumprida é a manifestamente ilegal (não apenas a criminosa)
 - Para a prova, atente-se à letra de lei

QUADRO EXPOSITIVO – ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 39. <u>Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa</u> ”.	1) Adoção da teoria diferenciadora: estado de necessidade exculpante (art. 39) e estado de necessidade justificante (art. 43). 2) O bem protegido deve ser do agente do fato necessário ou de pessoa querida (parente ou afeição); no justificante, pode ser de qualquer pessoas. 3) O direito sacrificado pode ser superior ou igual ao protegido; no justificante deve ser apenas inferior. 4) Não se exclui o EN quando o agente tem o dever de arrostar o perigo, diversamente do que dispõe o justificante. 5) Atenção para a Súmula 3 do STM: “Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas”. Vide art. 296 do CPPM.

- Estado de necessidade exculpante (art. 39) – protege-se direito próprio ou de terceiro ligado por estreitas relações.
 - Note a especificação do CPM que o direito deve ser de alheio com afeição/relação com aquele que pratica – liame de afeição – (no estado de necessidade justificante pode ser qualquer direito alheio)
 - **CPM fala na exculpação:** há previsão de sacrifício de direito alheio, ainda quando superior ou igual ao protegido.
 - Proteção de vida por vida.
 - Desde que não lhe era exigível razoavelmente conduta diversa.
 - Obs. dever militar como bem jurídico **superior**
 - Lembre-se que é necessário a ponderação de bens
 - ex. militar comete deserção; ao se apresentar no quartel, explica que o pai teve AVC sendo necessário seu auxílio para cuidar de afazeres domésticos; note que houve o sacrifício de bem jurídico “dever/serviço militar” (bem jurídico de grande valor no âmbito militar) para proteger um bem menor
 - obs. atente-se que deve haver provas das alegações (no exemplo acima, demonstrar o AVC e sua necessidade na realização dos afazeres domésticos, por exemplo)

- Repito: Estado de necessidade justificante (art. 43) –
 - protege-se direito de **qualquer pessoa**;
 - sacrifício **apenas** de direito/bem inferior.
- No artigo 39 não há previsão do arrostamento de conduta.

➤ **DOLO E CULPA (CULPABILIDADE)**

QUADRO COMPARATIVO	
CPM	CP
“Art. 33. Diz-se o crime: Culpabilidade I - doloso, quando o agente <u>quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo</u>; II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que <u>podia prever</u> ou, prevendo-o, <u>supõe levemente</u> que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Excepcionalidade do crime culposo Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Nenhuma pena sem culpabilidade Art. 34. Pelos resultados que agravam especialmente as penas só responde o agente quando os houver causado, pelo menos, culposamente”.	“Art. 18 - Diz-se o crime: Crime doloso I - doloso, quando o agente <u>quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo</u>; Crime culposo II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por <u>imprudência, negligência ou imperícia</u>. Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Agravação pelo resultado Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente”.

- No causalismo embrionário, dolo e culpa eram espécie de culpabilidade
- O CPM traz um estágio evoluído do causalismo (neokantismo) em que a culpabilidade possui dolo e culpa, como no clássico, adicionando outros elementos (sendo psicológica e normativa)
- Kelsen tira o dolo e a culpa da culpabilidade e leva ao fato típico, retirando o elemento psicológico da culpabilidade e destaca outro elemento que estava no dolo, a consciência da ilicitude (culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa)
- CPM traz dolo como cognição, vontade e consciência da ilicitude – teoria psicológico normativa
- No CP: apenas vontade e cognição
- CPM descreve culpa consciente e inconsciente.
 - **Culposo**: inciso II art. 33 CPM.
 - Culpa consciente (prevendo o resultado, levemente acredita que pode ser evitado) e
 - Inconsciente (não prevê o resultado)
 - **Veja, portanto, que o CPM define expressamente as espécies de culpa**
 - Enquanto as modalidades de culpa NÃO são mencionadas expressamente (quem faz isso é o CP: imprudência, negligência e imperícia)

- Não quer dizer que não se utilizem/adotem as modalidades no CPM, mas que o legislador não se preocupou em citar ou definir (ex. em alguns preceitos secundários se fala em negligência: art. 324 do CPM¹)
- Parágrafo único traz o princípio da excepcionalidade do crime culposo (culpa é exceção que deve ser expressa na lei)
- Doloso: inciso I art. 33 CPM.
 - Dolo direto e
 - Dolo eventual (indireto).
- Elementos do dolo (dolo normativo; dolo malus):
 - **Elemento** intelectual (cognitivo).
 - **Elemento** volitivo.
 - **Atual** (não potencial) consciência da ilicitude (vide o erro de fato essencial que exclui o dolo na discriminante putativa, equiparada à primeira hipótese).
- Exclusão do dolo e culpa significa exclusão da culpabilidade e, portanto, exclusão do crime (teoria tripartite). (no CP gera a exclusão de tipicidade)
- Na prática, muitos aplicam a estrutura do CP na Justiça Militar.
 - Nenhuma pena sem culpabilidade.
 - CPM descreve culpa consciente e inconsciente.
 - CP prevê apenas modalidades de culpa.

¹ Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar:

Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano.

- **Erro de direito e erro de fato** (obs. ainda dentro de dolo e culpa)

QUADRO COMPARATIVO – ERRO DE DIREITO E ERRO DE PROIBIÇÃO	
CPM	CP
“Art. 35. A pena <u>pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave</u> quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, <u>supõe lícito o fato</u> , por ignorância ou erro de interpretação da lei, <u>se escusáveis</u> ” (atenuação de 1/5 a 1/3 , pelo art. 73 do CPM).	“Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O <u>erro sobre a ilicitude do fato</u> , se <u>inevitável</u> , <u>isenta de pena</u> ; se <u>evitável</u> , poderá <u>diminuí-la de um sexto a um terço</u> . Parágrafo único - Considera-se <u>evitável</u> o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe <u>era possível</u> , nas circunstâncias, <u>ter ou atingir essa consciência</u> ”.

- erro de direito não equivale ao erro de proibição
- Exceção para “ alegação de o desconhecimento da lei ser inescusável”.
- Não há isenção de pena.
- **No art. 35 – erro de direito:**
 - erro na consciência de ilicitude
 - a ignorância da não escusa, mas pode levar a uma atenuação ou substituição da pena
 - Não há possibilidade de isenção de pena nesse caso, apenas a mitigação da culpabilidade (por atenuação de pena ou substituição por uma pena mais branda);
 - Não se aplica a alguns crimes (crimes contra o dever militar – vide quadro abaixo)
- **No CP é possível a isenção de pena (se inevitável).**
 - fala-se, também, em culpabilidade
 - fala-se em consciência de ilicitude POTENCIAL
- No erro de direito trata da consciência de ilicitude REAL
- Para o prof. esse dispositivo do art. 35 é inconstitucional, pois fere o princípio da culpabilidade sob o aspecto da vedação a uma responsabilidade penal objetiva.
 - ex. art. 226 do CPM – violação de domicílio; agente ingressa em local considerado como casa pelo CPM, sem conhecer essa equiparação legal (ignora a lei);
 - No exemplo, se fosse aplicar a matriz do CP, o agente estaria ignorando elemento que compõe o próprio tipo penal (seria erro de tipo) – erro de tipo permite a exclusão do dolo, remanescendo a possibilidade de crime culposos, se houver previsão nesse sentido

- Aplicando o CPM, o agente está ignorando a lei penal militar e não tem consciência de que pratica algo ilícito; utiliza-se o art. 35, não existindo isenção de pena, sendo punido (mesmo não tendo consciência de ilicitude) pelo crime de violação de domicílio com a pena atenuada ou substituída por mais branda (demonstrando um resquício de responsabilidade penal objetiva)

▪ **obs. para prova:** utilizar a letra da lei do art. 35

QUADRO EXPOSITIVO – ERRO DE DIREITO	
PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 35. A pena <u>pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave</u> quando o agente, salvo em se tratando de <u>crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato</u> , por ignorância ou erro de interpretação da lei, <u>se escusáveis</u> ” (atenuação de 1/5 a 1/3 , pelo art. 73 do CPM).	1) Base é a ignorância ou erro de interpretação da lei (não do fato). “A ignorância da lei não escusa!”. 2) Não coincide com erro de proibição. 3) Não se aplica a crimes contra o dever militar (arts. 183 a 204 do CPM). 4) Não permite a isenção de pena. 5) Mesmo no erro escusável ou inevitável permite o apenamento: resquício indesejável de responsabilidade penal objetiva, pois haverá sanção penal sem dolo ou culpa.

○ Erro de fato essencial (ainda dentro do dolo e culpa)

QUADRO COMPARATIVO – ERRO DE FATO E ERRO DE TIPO ESSENCIAIS	
CPM	CP
“Art. 36. <u>É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima.</u> Erro culposo § 1º - Se o erro <u>deriva de culpa</u>, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. Erro provocado § 2º - Se o erro é <u>provocado por terceiro</u>, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso”.	“ Art. 20 - O <u>erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo</u>, se previsto em lei. Descriminantes putativas § 1º - <u>É isento de pena</u> quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, <u>supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima</u>. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro § 2º - Responde pelo crime o <u>terceiro que determina o erro</u>”.

▪ **Erro de fato não é igual ao erro de tipo do CP**

- Observe que no erro de fato há a isenção de pena (lembre-se que o dolo, no CPM, está na culpabilidade)
- Enquanto no erro de tipo há a exclusão do dolo
- Para a maioria da doutrina, o §1º do CP é entendido como erro de proibição

QUADRO EXPOSITIVO – ERRO DE FATO ESSENCIAL

PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Erro culposo § 1º - Se o erro <u>deriva de culpa</u>, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. Erro provocado § 2º - Se o erro é <u>provocado por terceiro</u>, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso”.	1) Base é a falsa compreensão do fato (não da lei). 2) Não coincide com o erro de tipo do CP. 3) Possui duas hipóteses: suposição de inexistência de circunstância de fato ou existência de situação de fato que justificaria a conduta (descriminante putativa). 4) Em ambas as hipóteses o dolo estará excluído: pela ausência de cognição (primeira hipótese) ou pela ausência da atual consciência da ilicitude (segunda hipótese - dolo normativo). 5) Permite a punição por culpa em ambas as hipóteses (culpa imprópria na segunda hipótese, como no final do § 1º do art. 20 do CP) .

▪ **A base do erro de fato essencial:** é a falsa compreensão do fato (não da ilicitude)

▪ **Erro de fato essencial possui duas hipóteses**

- I) Erro sobre o elemento fático

- ❖ Escusabilidade do erro deve ser aferível
- ❖ Inexistência de circunstância de fato que constitui o delito
- ❖ Agente atua inebriado por um erro na circunstância fática que supõe inexistir
- ❖ Essa circunstância é essencial para a configuração do delito
- ❖ Ex. Militar “A” coloca sua arma sob a cama de militar “B”; Esse militar “B” pega a arma achando que era sua e leva para casa; Fato típico em tese é o furto (art. 240 do CPM); o militar “B” supõe inexistir a condição de coisa alheia – erro de fato
- ❖ Tem como consequência de afastar o dolo (possível a punição culposa quando prevista), sendo isento de pena

- ii) Erro sob a discriminante putativa

- ❖ Existência de situação de fato que tornaria a ação legítima
- ❖ Agente supõe existir situação de fato justificante, que na verdade não existe
- ❖ Também torna isento de pena
- ❖ Ex. legítima defesa e estado de necessidade putativos
- ❖ ex. determinado quartel da PM tinha notícia de queriam invadir o local; em determinado dia, um sargento chega para trabalhar (com essa ameaça de que iriam invadir o quartel na cabeça); observa uma cena de PMs, com armas em punho, abordando pessoas em trajes civis; o sargento acha que os civis estavam invadindo o local, conforme ameaça noticiada; o sargento aborda os civis, que sacam suas armas, levando o

sargento a atirar; após o fato, observa-se que não eram civis, mas sim PMs participando de uma simulação de ocorrência;

- ❖ Veja que o sargento supunha existir situação fática (legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal) que, se efetivamente existisse, tornaria sua conduta lícita

▪ **OBS. Erro decorrente de culpa** permite a punição, desde que haja crime culposos para tanto

▪ **Erro provocado por 3º:**

- Agente que está em erro de fato muitas vezes é instrumento de alguém que provoca o erro
- Quem provocou responderá dolosamente ou culposamente
- ex. médico militar que quer matar um paciente, sabendo que determinada dose levará o paciente a óbito; entretanto não quer ele injetar o medicamento; portanto, prescreve para que uma enfermeira injete aquela dosagem; a enfermeira não sabe que aquilo vai matar o paciente; a enfermeira é mero instrumento do crime; o médico irá responder por crime de homicídio doloso

○ Erro de fato acidental

QUADRO EXPOSITIVO – ERRO DE FATO ACIDENTAL	
PREVISÃO LEGAL (CPM)	OBSERVAÇÕES
“Art. 37. Quando o agente, por <u>erro de percepção</u> ou no <u>uso dos meios de execução</u>, ou <u>outro acidente</u>, <u>atinge uma pessoa em vez de outra</u>, responde como se tivesse praticado o crime contra <u>aquela que realmente pretendia atingir</u>. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa, para configuração, qualificação ou exclusão do crime, e agravação ou atenuação da pena. Erro quanto ao bem jurídico § 1º - Se, por erro ou outro acidente na execução, é <u>atingido bem jurídico</u> diverso do visado pelo agente, responde este por culpa, se o fato é previsto como crime culposos. Duplicidade do resultado § 2º - Se, no caso do artigo, é <u>também atingida a pessoa visada</u>, ou, no caso do parágrafo anterior, <u>ocorre ainda o resultado pretendido</u>, aplica-se a regra do art. 79”.	1) Base do <i>caput</i>: erro de percepção (erro <i>in persona</i>), no uso dos meios de execução (<i>aberratio ictus</i>) ou outro acidente. 2) Base do § 1º: erro ou acidente na execução (<i>aberratio criminis</i> resultado único). 3) § 2º, parte final: <i>aberratio criminis</i> de resultado complexo. 4) Possível também se falar <i>aberratio causae</i> e <i>error in objecto</i>. 5) Consequências: responde pelo delito pretendido (erro <i>in persona</i> e <i>aberratio ictus</i>), apenas culposamente (<i>aberratio criminis</i>) ou em concurso (casos do § 2º).

▪ **Erro de fato acidental** - pessoa quer delinquir, mas o pratica de forma equivocada:

- (lembre-se que no essencial não há a vontade de delinquir)
- Erro sobre a pessoa
- Erro sobre execução
- **Obs. em ambos acima** o agente responde como se tivesse efetivamente atingido a pessoa que almejava (responde de acordo com a qualidade da vítima potencial e não da efetiva)
 - ❖ ex. soldado X queria matar o cabo Y e acaba por atingir o soldado Z
 - ❖ se matasse o cabo, poderia responder por violência contra superior com resultado morte (art. 157 do CPM)

- ❖ ainda que tenha matado outro soldado (vítima real), irá responder como se efetivamente tivesse matado o cabo (vítima potencial)
- ❖ se, no exemplo, fosse morto um civil ao invés do soldado Z (ainda querendo atingir o cabo); aplica o art. 37 para subsumir à conduta do art. 157; **há duas posições**: i) Ronaldo Roth entende que o erro de execução pode levar à fixação da competência da justiça militar (no exemplo, considera que foi morto um militar e não o civil, ou seja, considera a vítima potencial); ii) professor Cícero entende que não pode misturar o art. 37 (direito material) com a competência de julgamento (direito processual), fato que levaria para o tribunal do júri (no exemplo)
- ❖ “**Art. 157.** Praticar violência contra superior:
§ 4º Se da violência resulta morte:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.”

- Erro sobre bem jurídico

- ❖ Responde por culpa se o fato é previsto como crime culposos
- ❖ aberratio criminis (crime que muda)
- ❖ ex. fulano quer atingir ciclano com uma pedra; ao arremessar a pedra, acabar por errar ciclano e atinge um automóvel; veja que queria lesão corporal, mas causou o crime de dano
- ❖ Responde pelo segundo fato, à título de culpa, se houver previsão da modalidade culposa

- Duplicidade de resultado

- ❖ Aplica-se a regra do concurso de crimes do art. 79 do CPM
- ❖ Penas de mesma natureza: acúmulo material
- ❖ Penas de natureza diversa: certa exasperação
- ❖ “**Art. 79-A.** Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até metade..”

➤ QUESTÃO:

- **Acerca do tratamento dado ao erro no direito penal pátrio, analise as proposições abaixo e depois assinale a alternativa INCORRETA (Questão 12 - 11º Concurso MPM - 2013).**

A. O erro de direito (art. 35 do CPM) se relaciona com a ignorância ou falsa interpretação da lei. É mais severo que o tratamento dado pelo Código Penal comum, pois, mesmo sendo invencível o erro (escusável) não exclui o dolo, mas apenas atenua ou permite a substituição da pena.

- B. O erro de fato (art. 36 do CPM) incide sobre o fato que constitui o crime, e se apresenta de duas formas: a. engano quanto a circunstância de fato que constitui o crime (atualmente é erro de tipo); b. engano quanto a circunstância que se existisse tornaria a ação legítima (descriminante putativa).
- C. Existe uma correspondência entre as denominações “erro de tipo” e “erro de proibição”, vigentes no direito penal comum, com as denominações “erro de fato” e “erro de direito”, previstas no direito penal militar.
- D. O erro de tipo, tratado no art. 20 do CP, incide sobre os elementos do tipo, ou seja, sobre um dos fatos que compõe um dos elementos do tipo. Também pode recair sobre um dos elementos normativos do tipo. Seu efeito é a exclusão do dolo porque não há no agente a vontade de realizar o tipo objetivo. Permite, no entanto, a punição por crime culposos, se previsto em lei.

Resposta: C.

Análise as proposições abaixo e assinale a resposta correta (Questão 19 - 11º Concurso MPM - 2013).

I – Um cadete da PM, com 17 anos de idade, durante o desfile de 7 de setembro, desentende-se com um cadete do Exército, que estava em forma no pelotão ao lado do seu, desferindo no militar do EB um golpe com a coronha do fuzil, lesionando-o gravemente (CPM, art. 209, § 1º). A competência para processo e julgamento é da Justiça Militar da União.

II – Militar de 17 anos, desde que tenha desenvolvimento psíquico suficiente para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento (CPM, art. 50) é penalmente imputável. A norma penal militar está em consonância com o art. 5º, § 2º, da Lei do Serviço Militar [será permitida a prestação do serviço militar como voluntário a partir dos 17 anos de idade] e, com o art. 5º, parágrafo único, inciso III, do Código Civil de 2002 [cessa, para os menores, a incapacidade, pelo exercício de emprego público efetivo]

III – O Código Penal Militar, na esteira do revogado Código Penal comum de 1969 (revogado sem nunca entrar em vigor), acabou com as medidas de segurança para imputáveis e aboliu o sistema do duplo binário para semi-imputáveis, substituindo-o pelo denominado sistema vicariante, segundo o qual, o juiz ou impõe pena ou medida de segurança, vedada a cumulação de ambas.

IV – Tanto no Código Penal comum, como no Código Penal Militar, a emoção como a paixão não excluem a imputabilidade penal.

A – I, II, III e IV estão corretas

B – I e II estão corretas e III e IV estão erradas

C – a III está correta e a IV está errada

D – a I está errada e a IV está correta

Resposta: C.